

育附加、罚款、滞纳金及尚未扣缴的个人所得税予以扣除和认定。

二、单位缴纳的“费”“罚款”“滞纳金”等不应纳入逃税范畴

1. 教育费附加及地方教育附加作为“费”，不属于逃税罪调整的范畴。根据《征收教育费附加的暂行规定》，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和 个人，除按照规定缴纳农村教育事业发展费附加的单位外，都应当依照规定缴纳教育费附加。教育费附加是国家为扶持教育事业发展，计征用于教育的政府性基金。教育费附加以单位和个人实际缴纳的增值税、营业税、消费税的税额为计征依据。虽然教育费附加是由税务机关负责征收，但却不属于“税”而是“费”的范畴，本质系政府规费，属于财政管理范围。故，本案中公诉机关指控的教育费附加以及地方教育附加不应认定为逃税罪的税款数额。

2. “税”与“费”的区别。税收是指国家为满足社会公共需要，凭借公共 权力，按照法律所规定的标准和程序，参与国民收入分配强制无偿地取得财政收入的一种方式。而“费”是政府有关部门为单位或居民个人提供特定服务，或被赋予某种权利而向直接受益者收取的对价。“税”与“费”区别在于其征收主体不同，“税”的征收主体为税务、海关、财政等部门，而“费”的征收主体为行政事业单位、行业主管部门，实务中也存在税务机关代收的情况；“税”与“费”的特征不同，“税”具有无偿性、稳定性的特点，而“费”具有补偿性、灵活性的特点；在用途上，“税”一般用于社会公共需要支出，“费”一般具有专款专用的性质。

3. 行政处罚的罚款及滞纳金不应纳入逃税范畴。《中华人民共和国刑法》第二百零一条第四款作为出罪条款是刑法唯一规定附条件不予追究刑事责任的条款。根据该特别条款的规定，对于逃税罪的初犯，虽然其逃税行为已经符合《中华人民共和国刑法》第二百零一条第一款或第二款规定，但若能够在税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事责任。该特别条款规定的目的在于寻求刑法手段与行政手段综合治理的优势，体现了宽严相济刑事政策与行政执法的有机衔接。事实上，税务机关的罚款及滞纳金是基于被告单位不积极履行缴税义务，因迟延缴纳税款引起

的行政处罚措施，是一种行政责任承担形式，并不是单位所逃税款数额。故，本案中公诉机关指控的行政罚款及滞纳金不应认定为逃税罪的税款数额。

4. 罚款与滞纳金的属性和目的。罚款是行政处罚手段之一，是行政执法单位对违反行政法规的个人和单位给予的行政处罚。滞纳金是指行政机关对不按期履行金钱给付义务的相对人，增加新的金钱给付义务的方法。就目的而言，罚款的目的是对纳税人的行政违法行为的经济制裁，起到教育其不再违法的目的，具有告诫作用；滞纳金是以促使纳税人自觉履行纳税义务为目的。

三、不应当将尚未代为扣缴的个人所得税纳入逃税范畴

《中华人民共和国个人所得税法》第九条规定，个人所得税以所得人为纳税人，以支付所得的单位或个人为扣缴义务人。据此，个人所得税本身不是企业应缴税种，而是企业作为扣缴义务人代为扣缴的税种之一。《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第二款规定，扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款50%以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。《中华人民共和国刑法》第二百零一条第二款规定，扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，税额较大的，依照前款的规定处罚。根据上述规定，扣缴义务人不缴或者少缴的对象必须是已扣、已收税款，如果税款尚未已扣、已收，则不存在不缴、少缴问题，进而不构成逃税罪。本案中，置业公司虽是个人所得税扣缴义务人，但会计凭证账目等证据证实程某所用款项属于企业应收账款，程某与置业公司之间系借款关系，税务机关仅根据该款项没有在纳税年度内归还而视为股息红利分配。事实上，置业公司未经过股东大会决议进行分红，程某主观目的是转移款项对外投资其他项目，而非自己红利所得。因此，从主客观方面均不应当将该款项作为个人所得税的征收依据，置业公司没有实际扣缴到个人所得税，就不存在不缴或者少缴税款的行为，故本案中公诉机关指控的尚未代为扣缴的个人所得税不应认定为逃税罪的税款数额。

链条式虚开增值税专用发票案中享有合法进项的 第一手企业“卖票”行为构成虚开增值税专用发票罪

——李某某、石油化工公司虚开增值税专用发票案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

重庆市第一中级人民法院(2023)渝01刑终162号刑事裁定书

2. 案由：虚开增值税专用发票罪

【基本案情】

童某某、杨某某、武某某等三人(均已另案判决)实际控制了某甲实业有限公司(经营范围不含石油类商品销售)、某乙实业有限公司(经营范围不含石油类商品销售)等23家公司,以“倒卖”增值税专用发票为主要活动,先以票面金额2%~3%的“点子费”向被告单位石油化工公司等上游企业购买虚开的进项增值税专用发票,后通过内部循环开票的方式开具下游受票企业需要的增值税专用发票,再以票面金额8%~11%的“点子费”向下游受票企业出售。

2019年3月至11月,某甲实业有限公司、某乙实业有限公司以票面金额3%的“点子费”向被告单位石油化工公司、被告人李某某非法购买虚开的石油类商品销项增值税专用发票464张。其中,某甲实业有限公司446张,涉及税额5760097.14元,价税合计49392620.5元;某乙实业有限公司18张,涉及税额231526.58元,价税合计2012500元。被告单位石油化工公司、被告人李某某从中非法获取“点子费”1542153.61元[合计票面金额(49392620.5+

2012500)元 $\times$ 3%]。某甲实业有限公司从成立至2020年6月8日,共对外开具增值税专用发票168617284.06元,其中有133192605.23元发票已认证抵扣。经查,某甲实业有限公司、某乙实业有限公司等23家公司向机械制造公司等15家下游受票企业出售虚开的433份增值税专用发票,已被受票企业在真实销售货物中认证抵扣税款,给国家造成税款损失共计6417991.75元。

另外,被告单位石油化工公司已被税务机关处以没收违法所得1542153.61元和罚款500000元的行政处罚,且被告单位石油化工公司于2021年8月16日向税务机关缴纳罚款100000元。

【案件焦点】

享有合法进项的第一手企业即石油化工公司为赚取“点子费”“卖票”的行为应当如何定性。

【法院裁判要旨】

重庆市沙坪坝区人民法院经审理认为:在“被告单位石油化工公司为赚取‘点子费’‘卖富余票’→某甲、某乙实业有限公司(中间商)为满足客户需求‘倒票’→机械制造公司等骗取抵税企业为抵扣税款‘用票’”虚开链条中,被告单位作为享有合法进项的第一手企业,为牟取非法利益,违反国家税收征管法规,为他人虚开增值税专用发票,且虚开的增值税专用发票经某甲、某乙实业有限公司(中间商)“倒票”后,被机械制造公司等骗取抵税企业用于抵扣税款,造成国家税款损失明显超过250万元,虚开的税款数额巨大,构成虚开增值税专用发票罪。被告人李某某作为被告单位的法定代表人,安排实施虚开增值税专用发票,系直接负责的主管人员,亦构成虚开增值税专用发票罪。被告单位、被告人李某某具有自首情节,其对认定虚开增值税专用发票罪的罪名有异议,但不影响认罪认罚的认定。据此,以虚开增值税专用发票罪,判处被告单位石油化工公司罚金50万元(折抵已向税务机关缴纳的10万元罚款,尚需缴纳罚金40万元),并追缴其违法所得1542153.61元;判处被告人李某某有期徒刑六年六个月。

一审宣判后，被告人李某某以其构成非法出售增值税专用发票罪，不构成虚开增值税专用发票罪及量刑过重为由提出上诉。

重庆市第一中级人民法院经审理认为：原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。二被告主观上明知增值税专用发票的用途和功能，为获取不法利益，在没有真实交易的情况下，为他人虚开增值税专用发票，其行为符合虚开增值税专用发票罪的构成要件。原审被告单位石油化工公司、上诉人没有直接骗取税款，可作为量刑情节酌情考虑，但不影响行为性质的认定。据此，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

企业在实际经营过程中，会因购买方不需要增值税专用发票等原因，产生 多余的销项即“富余票”。为赚取“点子费”，第一手企业可能将“富余票”虚开给开票公司（中间商），后开票公司（中间商）再向骗取抵税企业进行虚开，因享有“富余票”的企业与骗取抵税企业之间不存在直接的虚开行为，被告人及其辩护人、检察院、法院对享有“富余票”的企业的行为定性时常发生 分歧，本案即是如此。本案中，控辩双方、人民法院对享有合法进项的第一手 企业即石油化工公司为赚取“点子费”“卖票”的行为是构成非法出售增值税专用发票罪还是虚开增值税专用发票罪，存在较大争议。

第一种观点认为，构成非法出售增值税专用发票罪。理由有二：其一，被告单位石油化工公司与某甲实业有限公司、某乙实业有限公司之间没有真实的 交易，不会产生增值额，不具备征税条件，不会导致国家税款损失。其二，某甲、某乙实业有限公司与机械制造公司等骗取抵税企业之间的虚开行为是否造成国家税款损失与被告单位石油化工公司无关。

第二种观点认为，构成虚开增值税专用发票罪。理由有二：其一，机械制造公司等骗取抵税企业用于抵扣合法销项税额的进项税额实际源于被告单位石油化工公司，其虚开行为与国家税款损失之间存在法律上的因果关系；其二，被告单位石油化工公司的直接目的虽是赚取“点子费”，但对虚开行为最终造

成国家税款损失持放任态度。①

笔者同意第二种观点，即构成虚开增值税专用发票罪，具体解析如下。

一、被告单位石油化工公司的行为客观上造成国家税款损失

一是国家征收增值税的条件和造成国家税款损失的环节。增值税是以商品（含应税劳务）在生产、流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。销售方是纳税人，购买方支付货款获取的进项增值税专用发票金额包含销售方已向国家缴纳的税款，产生进项税额。购买方在生产、流转过程中向下游受票企业开出销项增值税专用发票时，产生销项税额，因重复缴纳了进项价款中已向国家缴纳的税额，可以用合法进项税额向税务机关申报抵扣合法销项税额。据此，在构成虚开增值税专用发票罪的案件中，必然存在虚开和抵扣两个环节。本案中，虚开模式为链条式，存在两个虚开行为，被告单位石油化工公司将在真实货物交易中获得的合法进项税额，通过虚开方式转移给某甲实业有限公司、某乙实业有限公司；某甲实业有限公司、某乙实业有限公司根据机械制造公司等公司的实际需要，通过变票处理后，又通过虚开方式将进项税额转移给机械制造公司等企业；机械制造公司等企业用非法获取的进项税额抵扣其与下家真实交易中合法产生的销项税额，进而导致国家税款损失，且损失金额明显超过250万元。

二是虚开链条上的第一手企业的行为与国家税款损失之间存在法律上的因果关系。本案中，只有一个环节存在税款损失，即机械制造公司等骗取抵税企业，在真实交易过程中，将非

法购买的进项税额抵扣合法产生的销项税额，其 余环节因不存在真实的交易或纳税义务人系卖方，并不存在国家税款损失。但 虚开链条的开端始于合法进项，末端终于合法销项，某甲实业有限公司、某乙 实业有限公司仅是起到牵线搭桥、中间商的作用，无论经历多少中间环节，最 终用于抵税的进项税额是源于被告单位石油化工公司，故其虚开行为与最终的 国家损失存在法律上的因果关系。

①傅忆文：《虚开增值税专用发票罪的保护法益及其运用》，载《中国检察官》2021年第6期。

二、被告单位石油化工公司对其合法享有的进项税额非法流转至下游企业且非法被用于抵扣销项税额、造成国家税款损失持放任态度

虚开增值税专用发票罪既遂要求行为人主观上具有骗取抵扣国家税款的故意，客观上造成国家税款损失。①从虚开增值税专用发票罪的立法原意和构成要件看，该罪的主观方面为故意。在行为人具有多重目的或者链条式虚开增值税专用发票案件中，行为人的主观目的难以探究，若只有直接故意方可构成此罪，势必会导致虚开行为与抵扣行为的割裂，不利于打击妨碍增值税征管秩序的犯罪行为。故，虚开增值税专用发票罪的主观方面既包括直接故意，也包括间接故意。②本案中，被告单位石油化工公司明知某甲实业有限公司、某乙实业有限公司未开展实际经营，不具有销售石油类商品的资质，以“倒卖”增值税专用发票为业，向其购买增值税专用发票不可能是用于虚增业绩、融资、贷款等非骗税目的，且明知虚开的增值税专用发票最终可能被用于抵扣税款，但为了赚取“点子费”，仍进行虚开将其合法享有的进项税额转移给某甲实业有限公司、某乙实业有限公司，可以认定其对虚开行为造成国家税款损失持放任态度，具有间接故意。

综上所述，享有“富余票”的第一手企业，明知开票公司（中间商）“倒卖”增值税专用发票，仍向开票公司虚开，再由开票公司（中间商）向下游骗取抵税企业虚开，该链条式虚开行为的社会危害性与第一手企业直接向骗取抵税企业进行虚开的社会危害性并无二致，甚至因开票公司（中间商）的存在，整合了第一手企业赚取“点子费”、下游企业骗取抵扣国

家税款的需求，让虚开增值税专用发票的犯罪行为更为频繁、猖獗。所以，本案判处被告单位石油 化工公司构成虚开增值税专用发票罪，符合罪刑法定原则与罪责刑相适应原则。

编写人：重庆市沙坪坝区人民法院 黄燕 毕汇林 田 昆

①张明楷：《刑法学》，法律出版社2021年版，第1059页。

②最高人民法院中国运用法学研究室编：《人民法院案例选》（第154辑），人民法院出版社2021年版，第152页。

(七) 侵犯知识产权罪

51

避开技术保护措施行为构成侵犯著作权罪的刑法规制路径

—— 刘某某侵犯著作权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市普陀区人民法院(2023)沪0107刑初155号刑事判决书

2. 案由：侵犯著作权罪

【基本案情】

某有限公司及其关联公司享有某安全系统、算码器软件等某品牌医疗设备维修工具软件、升级功能软件、维修手册及加密文件等作品著作权，并授权某投资公司在中国境内行使。某安全系统及其加密狗系著作权人为保护上述作品著作权采取的技术措施。他人需经权利人许可后使用加密狗工具通过某安全系统核验，方能接触使用被加密隐藏的各类计算机软件功能、维修手册及加密文件等。

2020年3月至2022年7月，被告人刘某某以营利为目的，未经著作权人许可，从闫某(已判刑)、彭某(另案处理)等人处购入破解版加密狗、获取某品牌算码器软件、维修手册等作品，并利用互联网等渠道，故意向他人发行提供用于避开技术措施的破解版加密狗，通过信息网络向公众传播销售某品牌算码器软件、维修手册等作品。被告人刘某某非法经营数额合计人民币15万

余元。

2022年7月，公安机关在被告人住处扣押加密狗5套、手机1部、移动硬盘1个。经鉴定，在刘某某住处查获的5套加密狗、以及刘某某向证人马某某出售的1套加密狗均能够规避权利人为其作品采取的技术保护措施；刘某某百度网盘账户、以及刘某某向证人马某某出售的笔记本电脑中存储、安装的部分软件、文件，与权利人享有著作权的作品一致。

2022年7月，被告人刘某某被公安机关抓获，到案后如实供述上述犯罪事实。审查起诉期间，刘某某退出违法所得并预缴罚金人民币8万元。

【案件焦点】

1. 厘清“技术措施”之内涵，判断被控侵权行为是否构成避开技术保护措施行为；2. 判断被控侵权行为是否符合民事侵权和刑事犯罪构成要件，能否以侵犯著作权罪入罪。

【法院裁判要旨】

上海市普陀区人民法院经审理认为：被告人刘某某以营利为目的，未经著作权人许可，故意避开权利人为其作品采取的保护著作权的技术措施，利用互联网等渠道发行、通过信息网络向公众传播作品，并有其他严重情节，其行为已构成侵犯著作权罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。

据此，以侵犯著作权罪判处被告人刘某某有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币8万元。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

《中华人民共和国刑法修正案(十一)》将规避技术措施行为纳入“侵犯著作权罪”的规制路径，实现《中华人民共和国刑法》与《中华人民共和国著作权法》的衔接，扩大了对著作权的保护范围，亦顺应数字经济时代规制新型网络犯罪之需要。判断侵权行为的规制路径，应从民事侵权和刑事犯罪构成要

件两个方面论处。判断过程中，既要完善知识产权的刑法保护体系，又需谨慎 界定数字领域的刑法保护边界。

一、判断是否构成民事侵权，首先需厘清“技术措施”之内涵

1. 技术措施由著作权人或相关权利人用于作品或其他受保护客体。本案中，权利人采取“某安全系统+加密狗”双重加持的加密措施，保护隐藏的医疗设备维修工具软件等。其著作权标识明晰，可以推定权利人对上述作品享有 著作权。因而符合上述特征。

2. 技术措施具有阻止对作品或其他受保护客体实施特定行为的功能。本案中，需要配合使用“加密狗”登录某安全系统才能查阅、使用受保护作品。因此，“加密狗”可以阻止他人未经许可运行、使用计算机软件及查阅加密文件 等，符合上述要件。

3. 技术措施的保护目的应具有“正当性”。本案中，权利人在其医疗设备 终端安装的“某安全系统+加密狗”相当于“门禁卡”系统，其设计目的在于 保护软件功能及加密文件，不存在滥用技术措施危害社会公共利益的情形，其 保护目的具有正当性。

4. 技术措施的效力应具有“有效性”，即应当以一般用户掌握的通常方法 是否能够避开或者破解为标准。本案中，权利人对“加密狗”的管理采取了严 密的监管和限制措施，制定了严格的权限开放范围和开放期限制度。因此该加 密措施正常情况下足以有效阻断普通用户侵权可能性。

因此，“某安全系统+加密狗”符合技术保护措施之构成要件。行为人向他人销售、提供“加密狗”的行为属于“提供规避手段”的间接规避行为。

二、“提供规避手段”的间接规避行为是否具备可刑罚性？笔者认为需结合具体案情进行分析

1. 从前置法的立法规定看，《信息网络传播权保护条例》对“直接规避行为”和“提供规避手段”均作出禁止性规定，2020年修订的《中华人民共和国著作权法》吸收了《信息网络传播权保护条例》关于直接规避行为和间接规避行为的规定，基于法秩序的统一原则，《中华人民共和国刑法》中关于规避

技术措施的内涵应与前置法保持一致。

2. 分析本案被告人的行为方式和危害结果可以发现，其“提供规避手段”的间接规避行为与直接规避行为的行为性质在本质上是相同的，都是以侵犯著作权的手段对受保护作品实施特定行为，甚至本案中的间接规避行为由于其隐蔽性强难以被察觉，反而具有更大范围的传播性，从而产生更严重的社会危害性。在行为性质同质性和危害结果扩大化的情况下，本案中的间接规避行为亦应具有可刑罚性。

同时，从刑事犯罪构成要件来看，规避技术措施构成侵犯著作权罪，要求行为人一是具有主观故意，即明知规避技术措施行为会发生侵犯著作权的后果仍故意为之；二是以营利为目的，即规避技术措施行为是为了牟取经济利益；三是达到“违法所得数额较大”或者“有其他严重情节”的刑罚标准。本案中被告人的行为亦符合上述刑事犯罪构成要件。

因此，结合民事侵权判断与刑事犯罪构成要件判断，对本案被告人应以侵犯著作权罪入罪。

编写人：上海市普陀区人民法院 刘亚玲 张敏婕

“切机”行为侵犯著作权罪的认定

—— 苏某某侵犯著作权案

1. 判决书字号

广东省深圳市中级人民法院(2023)粤03刑终422号刑事裁定书

2. 案由：侵犯著作权罪

【基本案情】

深圳某公司系A、B型号POS机(一种非现金结算收款设备)生产商,对该两款POS机上安装的系统软件享有著作权。为保证支付安全和支付管理需要,深圳某公司会依照客户需求在出厂的POS机上设置相应的技术保护措施,并通过公钥来限制数据签名验证修改CID(中央信息区),以技术措施控制POS机只能安装特定支付机构的支付程序。被告人苏某某原系深圳某公司软件开发工程师,参与涉案POS机的软件开发及后期代码维护工作,于2021年4月离职。2021年3月至4月,苏某某利用职务之便登陆公司开发平台,对公司POS机固件源代码进行修改、编译生成切机程序。该切机程序通过修改代码的方式避开前述软件签名认证,破坏深圳某公司POS机的技术保护措施,使之可以任意指定支付机构。2021年5月,深圳某公司发现POS机出现“切机”问题,遂通过技术升级堵塞漏洞,苏某某的切机程序失效。2021年6月,已经离职的苏某某来到深圳某公司周边,利用在职期间深圳某公司分配给其的账号密码登陆深圳某公司的局域网开发平台,再次对公司POS机固件源代码进行修改、编译生成新的切机程序。经鉴定,两个切机程序均分为两部分代码,其中占主要部分、用于实现POS机功能的代码与深圳某公司享有著作权的代码相同;另一小部分代码使得程序能够未经授权获取POS机CID并修改CID参数,用于绕过POS机技术保护措施,该部分代码与深圳某公司享有著作权的代码不同。苏某某将两个切机程序出售给朱某并收取朱某60万元,将切机程序提供给刘某,约定刘某对外每切机一台,分给苏某某5万元,最终刘某通过切机软件获取14.4万元,分给苏某某12万元。

【案件焦点】

“切机”行为的犯罪认定。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市南山区人民法院经审理认为:被告人苏某某未经深圳某公司许可,登录公司系统平台对该公司享有著作权的POS机固件源代码进行修改,

故意破坏固件代码的技术防护机制，并下载、出售给朱某、刘某进行切机，以谋取不正当利益，其行为同时触犯非法获取计算机信息系统数据罪和侵犯著作权罪，根据从一重处罚原则，应以侵犯著作权罪定罪处罚。

广东省深圳市南山区人民法院依照《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第二百一十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》第十条之规定，判决如下：

一、被告人苏某某犯侵犯著作权罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币75万元；

二、在案扣押的一台笔记本电脑（华硕）予以发还，扣押的赃款30万元、一台POS机、一个U盘、一部台式电脑主机、一部手机、一台笔记本电脑予以没收；

三、继续追缴违法所得12万元，依法没收，上缴国库。

被告人苏某某以其未破坏涉案软件的技术措施，也未非法获取计算机信息系统数据等为由提出上诉。

广东省深圳市中级人民法院经审理认为：苏某某的切机软件虽然破坏了涉案软件的技术措施，但该技术措施是为实现绑定支付程序而采取的措施，是作为实现其实用功能的主体内容的一部分，而非为了保护作品著作权而设置，不属于侵犯著作权罪中所指的技术措施。苏某某未经许可复制发行涉案软件作品，其行为构成侵犯著作权罪。苏某某离职后使用其不再有权使用的账号密码登陆深圳某公司服务器，违背了深圳某公司的账号密码授权意愿，属于非法侵入深圳某公司的计算机信息系统，其侵入计算机信息系统后下载修改编译后的固件代码，获取该计算机信息系统中处理的数据，其行为构成非法获取计算机信息系统数据罪。

广东省深圳市中级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第一项之规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

随着技术发展和商业模式创新，实践中涌现出诸多新型犯罪形式，而数字经济环境下犯罪客体和犯罪行为的复杂情况对准确定罪量刑提出了司法挑战。本案针对“切机”这一新型技术行为，从知识产权犯罪和涉数据犯罪的构成要件出发，厘清了对“切机”行为破坏技术措施的认识误区，指出了其未经许可复制他人软件作品的行为本质。而针对以非法侵入他人信息系统的方式“切机”的，还就数据刑事犯罪与知识产权犯罪的竞合予以评析。围绕本案争议焦点，可从以下两个方面展开理解。

一、“切机”行为不构成规避技术措施型侵犯著作权罪的澄清

“切机”是指为了回收利用二手POS机，将设备的原系统软件更换为已破坏相关技术措施的新系统软件，从而重新任意指定POS机支付机构并实现设备原有其他功能的刷机行为。本案核心关键就在于如何理解侵犯著作权罪中的“技术措施”。软件技术措施泛指为实现某种软件功能或目的而从技术上采取的专门措施，但根据罪刑法定原则的要求，侵犯著作权罪中的技术措施系专指为保护著作权而设置的措施，即为防止、限制他人不经权利人许可而使用、传播作品的措施^①。对此，可以从如下方面理解《中华人民共和国刑法》在侵犯著作权罪中对“技术措施”的限缩解释。首先，从文义解释来看。《中华人民共和国刑法》第二百一十七条第六项^②规定了“规避技术措施型侵犯著作权罪”，该项法律规定从表述上明确限定了此处

的技术措施系特指“保护著作权或者与著作权有关的权利的技术措施”。其次，从体系解释来看。侵犯知识产权罪是法定犯、行政犯，其构成要件的解释需结合行政法的有关规定展开。根据《中

①全国人大常委会法制工作委员会刑法室编：《中华人民共和国刑法条文说明、立法理由及相关规定》，北京大学出版社2009年版，第806页。

②《中华人民共和国刑法》第二百一十七条第六项规定，未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可，故意避开或者破坏权利人为其作品、录音录像制品等采取的保护著作权或者与著作权有关的权利的技术措施的。

为使行文简洁，下文将该项中的“著作权或者与著作权有关的权利”统称为“著作权”，将“著作权人或者与著作权有关的权利人”统称为“著作权人”，将“作品、录音录像制品等”统称为“作品”。

《中华人民共和国著作权法》第四十九条第三款的规定，著作权法中规定的技术措施也是专指“用于防止、限制未经权利人许可浏览、欣赏作品、表演、录音录像制品或者通过信息网络向公众提供作品、表演、录音录像制品的有效技术、装置或者部件”，《中华人民共和国刑法》中的技术措施与《中华人民共和国著作权法》中的技术措施具有相同的本质属性。最后，从目的解释来看。“规避技术措施型侵犯著作权罪”是《中华人民共和国刑法修正案(十一)》为顺应作品保护的需求而新增的不法行为类型，将该行为犯罪化的目的在于提高犯罪成本、加强知识产权保护^①。网络时代下数字作品的传播较传统传播有了本质变化，信息技术使之传播手段更便捷、范围更广、效率更高，很容易在极短时间内就形成超大规模的传播；而流量经济也鼓励将作品大量传播至不以营利为目的的终端用户以吸引流量，直接阻碍著作权人财产利益的实现。而著作权的传统法律救济为单一侵权行为的事后程序救济，不仅时间长、成本高，难以及时、有效遏制侵权；著作侵权、犯罪行为“以营利为目的”的构成要件也无法约束不以营利为目的的网络终端用户。故，仅靠传统法律救济几乎无法适应网络时代的著作权保护需求，鼓励并保护权利人通过技术手段自力采取预防手段防止作品著作权侵权成为必然趋势。而为了避免技术上的“丛林法则”，相应地，只有在规制著作权侵权、犯罪的法律中将避开或者破坏前述技术措施的行为纳入，才有可能使权利人的技术性自力救济得到保障。相反，对于与保护著作权无关的技术措施，则与本罪保护的法益和立法目的无关，通过侵犯著作权罪予以保护缺乏合理依据。

因此，著作权人为保护著作权所设置的技术措施，与计算机软件实现自身实用功能的技术措施，在性质、功能上具有本质区别，需根据实际案情准确判断，避免将所有技术措施均认定为刑法上的技术措施。本案中，涉案计算机软件所安装的技术防护机制主要是为了绑定支付程序从而限制和指定支付机构，是其软件实用功能的组成部分，并非为了保护著作权，被告人破坏该技术措施

①全国人大常委会法制工作委员会刑法室编：《中华人民共和国刑法条文说明、立法理由及相关规定》，北京大学出版社2021年版，第809页。

的行为不能认定为“规避技术措施型侵犯著作权罪”。但被告人的“切机”，复制了绝大部分的涉案软件代码，仅以规避为目的修改了与技术措施有关的极小部分代码，其“切机”后复制发行的软件与涉案作品实质上相似，“切机”行为的本质是未经许可复制、发行涉案软件，构成《中华人民共和国刑法》第二百一十七条第一项^①规定的侵犯著作权罪。

二、“切机”行为多重社会危害性的评价

对于被告人苏某某第二次的“切机”行为，如前所述，除构成侵犯著作权罪外，其手段与第一次不同，系其在辞职后利用在职期间的账号密码登陆深圳某公司局域网开发平台，修改、编译生成新的切机程序后下载获得，该行为还构成非法获取计算机信息系统数据罪，具有多重社会危害性，定性上需进行全面、充分评价。

定罪方面。数据是指任何以电子或者其他方式对信息的记录^②。非法获取计算机信息系统数据罪中的“数据”需同时具备形式要件与实质要件，形式上数据以电子方式存在于计算机信息系统上，实质上数据具有承载信息的记录功能。而在现代信息社会，该信息载体有可能同时还具有知识产权属性、财产属性等多重属性。本案中，存储在某科技公司服务器上的涉案系统软件，虽然属于软件作品，但其以电子方式记录开发程序等信息，同时具备了形式要件与实质要件，亦属于非法获取计算机信息系统数据罪中的“数据”。而根据《中华人民共和国刑法》第二百八十五条第二款的规定，本罪实行行为由“非

法侵入”与“非法获取”两部分组成，对“非法”判断的要点在于行为人是否获得了授权或者具有其他法定理由。本案中，行为人离职后使用其不再有权使用的账号密码登陆深圳某公司服务器，违背了深圳某公司的账号密码授权意愿，超越了原账号密码的授权条件，属于“非法侵入”，其侵入后未经许可对POS机

①《中华人民共和国刑法》第二百一十七条第一项规定：“以营利为目的，有下列侵犯著作权或者与著作权有关的权利的情形之一……（一）未经著作权人许可，复制发行、通过信息网络向公众传播其文字作品、音乐、美术、视听作品、计算机软件及法律、行政法规规定的其他作品的”

②参见《中华人民共和国数据安全法》第三条第一款。

固件源代码进行修改并下载获取，属于“非法获取”，依法可成立本罪。

竞合方面。犯罪竞合解决的问题是一个行为违反数个法条时，应当如何适用刑法、科处刑罚的问题。其中，想象竞合是指一行为同时符合数个罪的构成要件，侵犯了数个法益且数个罪的法条之间没有重合关系。想象竞合系因同一行为具有多重社会危害性而触犯数个罪名。法条竞合是指一个行为触犯数个法条，数个法条规定的犯罪构成要件存在包含或交叉关系，只能适用其一。法条竞合系因同一行为同时触犯具有竞合关系的法条而触犯数个罪名。本案中，被告人苏某某的第二次“切机”行为，基于一个犯罪故意、实施一个犯罪行为，同时侵害了知识产权和计算机信息系统安全两种法益，结果触犯了侵犯著作权罪、非法获取计算机信息系统数据罪两个罪名，形成两罪的想象竞合。对于想象竞合，既要充分、全面评价，在判决书中有必要列明行为所触犯的数个罪名，发挥其明示机能；又由于只有一个行为，也要避免重复评价，按照“从一重处断”，即本案应当按照处罚较重的侵犯著作权罪定罪处罚。

编写人：广东省深圳市中级人民法院 张婷
陈思桐

盗印图书并在网络销售的行为性质认定

—— 卿某侵犯著作权案

1. 判决书字号

河北省沧州市中级人民法院(2024)冀09刑终15号刑事裁定书

2. 案由：侵犯著作权罪

【基本案情】

2021年1月，被告人卿某冒用他人身份信息在某平台注册某某图书馆，办理了虚假的营业执照、出版物经营许可证。2022年7月2日，某行政审批服务局作出撤销其出版物经营许可的决定。2022年4月左右，卿某在某平台注册百年某某，未办理营业执照、出版物经营许可证，在没有图书销售授权的情况下，非法复制他人享有著作权的《某重点中学高考总复习》（以下简称《高考复习》）系列图书等图书并在上述两店铺销售。经审计，卿某在上述两家店铺合计销售盗印、盗制《高考复习》系列图书701册，销售额为18379.31元；合计销售其他种类图书3769册，销售金额为134763.69元。

【案件焦点】

1. 未经著作权人授权，复制发行图书的行为如何定性；2. 无证在网店销售图书的行为如何定性。

【法院裁判要旨】

河北省肃宁县人民法院经审理认为：被告人卿某以营利为目的，未经著作权人许可，发行其文字作品，属其他特别严重情节，其行为构成侵犯著作权罪。公诉机关的指控成立，但指控侵犯销售的数额不准。综合全案，鉴定的《高考复习》系列图书5种样书属盗印、盗制的非法出版物，其余图书未经鉴定，且没有实物，不予认定为侵犯著作权的数额，本案侵犯著作权的数额为五本样书的销售数量即701册，金额为18739.31元。公诉机关指控卿某犯非法经营罪，但经审核，涉案两店铺实际销售其余书籍的数量为3769册，金额为134763.69元。被告人供述其个人违法所得约4万元，根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》之规定，本案未达到非法经营罪的立案追诉标准，公诉机关指控被告人卿某犯非法经营罪，指控不成立。被告人卿某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人卿某主动赔偿著作权人经济损失并取得谅解，可酌予从轻处罚。

河北省肃宁县人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百一十七条、第

六十七条第一款规定，判决如下：

被告人卿某犯侵犯著作权罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币12000元。

一审宣判后，河北省肃宁县人民检察院提出抗诉。

河北省沧州市中级人民法院经审理认为：经查，原判认定卿某的侵权图书数量、销售数额，系根据鉴定报告、审计报告认定，符合法律规定。关于未经鉴定且无实物部分的图书能否认定为犯罪数额问题，经查，本案侦查机关在对《高考复习》系列图书委托鉴定过程中仅提供了一审法院认定的5类样书，对其余系列图书未予以鉴定，在无法查明原审被告人的销售的其他图书是否为盗印的情况下，原判不予认定，并无不当。另，原审认定的犯罪数额，应属“其他严重情节”，量刑符合法律规定。

原审被告人卿某以营利为目的，未经著作权人许可，发行其文字作品，属其他严重情节，其行为构成侵犯著作权罪。一审法院根据卿某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度所作出的判决，认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。抗诉机关的抗诉意见不能成立，不予支持。

河北省沧州市中级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项规定，裁定：

驳回抗诉，维持原判。

【法官后语】

侵犯著作权犯罪中，制作和销售图书是两个行为，侵犯的客体不同，应分别评价。本案即涉及未经著作权人授权复制发行图书以及无证在网店销售图书的行为如何定性的问题。

一、侵犯著作权罪的构成要件分析

以营利为目的，实施《中华人民共和国刑法》第二百一十七条规定的侵犯著作权或者与著作权有关的权利的行为，违法所得达到数额较大或者有其他严重情节的，构成侵犯著作权罪。本罪的主观方面表现为故意，且以营利为目的。是否“以营

利为目的”是区分罪与非罪的关键要素。“以营利为目的”是指行

为人侵犯他人著作权的行为是为了获取非法利益，非教学科研、个人学习，而是作为商品进入流通。本罪侵犯的客体是国家的著作权管理制度以及他人的著作权和与著作权有关的权益。本罪客观方面表现为实施出版他人享有专有出版权的图书等侵犯著作权的行为，而且违法所得数额较大或者有其他严重情节的行为。本案中，被告人卿某在未得到著作权人授权的情况下，制作图书并在网络销售牟利，销售侵权复制品数量达到701册，金额为18739.31元，符合侵犯著作权罪的构成要件及立案标准，其行为构成侵犯著作权罪。

二、侵犯著作权罪的犯罪金额认定

实践中，以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品，或者出版他人享有专有出版权的图书，或者未经录音录像制作者许可，复制发行其制作的录音录像，或者制作、出售假冒他人署名的美术作品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(1)违法所得数额3万元以上的；(2)非法经营数额5万元以上的；(3)未经著作权人许可，复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品，复制品数量合计500张(份)以上的；(4)未经录音录像制作者许可，复制发行其制作的录音录像制品，复制品数量合计500张(份)以上的；(5)其他情节严重的情形。

侵犯著作权罪的犯罪金额认定，应为确定为非法出版物的图书。非法出版物的认定应以鉴定报告为依据。鉴定机构依法出具的鉴定报告，经法庭举证、质证、认证，能够成为定案依据。具体到本案，除在案的已鉴定的样书外，其余图书均已销售，无实物且未鉴定，是否为盗印无法查明，在案证据亦无法证实，不应认定，不应计算在侵犯著作权罪的犯罪金额内。侵权图书为盗印、盗制的图书，本案即为鉴定报告中认定的盗印、盗制的五类样书，犯罪金额为侵权图书销售数量乘以销售金额。

三、侵犯著作权罪与非法经营罪的区分认定

著作权作为知识产权的一部分，侵犯著作权罪系侵犯知识产权犯罪中一种，该罪侵犯的是著作权人的合法权益，而非法经营行为系扰乱市场经济秩序行为。

